



上海交通大学
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
KOGUAN LAW SCHOOL

商业秘密

内容提要

一、商业秘密的认定

二、侵犯商业秘密的行为

定义

- 我国的《反不正当竞争法》第10条把商业秘密定义为：
 - “不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。”
- 根据《反不正当竞争法》的定义，商业秘密具有以下三个要件：
 1. 秘密性
 2. 价值性
 3. 管理性（保密性）

1.秘密性

要件

- 商业秘密必须不为公众所知悉；
- 两个问题：
 - 谁是“公众”？
 - 何为“知悉”？

公众（1）

- 公众是否是一般社会大众？
- 如此解释的后果：
- 在化学界有一个人人皆知的秘密

$$X+Y=Z$$

- 但是作为一般人是不知道的。
- **A**公司以此公式生产**Z**。你是**A**公司的员工，离职后，把这个方程式用到自己创建的公司生产经营中。**A**公司到法院起诉你侵犯商业秘密。

公众（2）

- 此“公众”非彼“公众”。我们在《反不正当竞争法》里面一般认为这里的公众指的是业内人士。

公众（3）

- 公司内部员工算不算公众？
 - 法定**保密义务**：
 - 《公司法》：董事、高级管理人员
 - 其他人：无法定保密义务
- 交易伙伴呢？
 - 《合同法》第四十三条规定：“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。”

知悉（1）

- 该问题的实质是在什么范围内公开的信息不再是商业秘密；
- 一般认为能从公开发生的出版物、产品的公开销售和展示等渠道取得信息不再是商业秘密。

知悉（2）

- 最高院《解释》给出6种公众知悉的情形：
 1. 该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例；
 2. 该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得；**（容易获取）反向工程这种一般认为不属于，因此不能通过反向工程就可以否定秘密性**
 3. 该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露；
 4. 该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开；
 5. 该信息从其他公开渠道可以获得；
 6. 该信息无需付出一定的代价而容易获得。

2.价值性

问题

- 在正常情况下，商业秘密的价值性是不言而喻的。否则厂商也没有必要要对之进行保护。
- 但是在以下情形中，可能会产生一些疑惑。
 - 已经被弃之不用的商业秘密；
 - 无法商业化的商业秘密；（失败的经验）
 - 企业从公共领域搜集的信息。

都属于

商业秘密保护规定（征求意见稿）

- 第七条 本规定所称具有商业价值，是指该信息因其秘密性而具有现实的或者潜在的商业价值，能为权利人带来商业利益或竞争优势。符合下列情形之一的，可以认定为该信息能为权利人带来商业利益或竞争优势，但有相反的证据能证明该信息不具有商业价值的除外：
 1. 该信息给权利人带来经济收益的；
 2. 该信息对其生产经营产生重大影响的；
 3. 权利人为了获得该信息，付出了相应的价款、研发成本或者经营成本以及其他物质投入的；
 4. 涉嫌侵权人以不正当手段获取或者试图获取权利人的商业秘密的；
 5. 其他能证明该信息能为权利人带来商业利益或竞争优势的情形。

客户名单

- 第十八条 权利人经过商业成本的付出，形成了在一定期间内相对固定的且具有独特交易习惯等内容的客户名单，可以获得商业秘密保护。

客户名称的列表，无法显示出客户地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于相关公知信息的特殊客户信息，名称可通过公开渠道获知，无法构成经营秘密。

3.管理性（保密性）的认定

保密措施（1）

- 管理性也就是说商业秘密的权利人必须对商业秘密采取**合理的**保护措施。
- 没有相应保密措施的信息不能称之为商业秘密。
- 商业秘密的管理性要求权利人必须要在企业内部建立起一套完备的商业秘密保护措施，否则其商业秘密有可能被法院不认可。

衡量完备保密措施的因素

- 形式要求：
 1. 有专人看管；
 2. 有专门的存放地点；
 3. 设置保密级别；
 4. 将保密文件和公开文件分别管理。
- 实质要求：
 1. 与相关人员签订保密协议和竞业禁止协议；
 2. 与关系单位签订保密协议和竞业禁止协议；

有保密义务

技术许可合同约定了保密期限，当约定的保密期限届满后，当事人是否仍有保密义务？

上海富日商业秘密纠纷申请再审案

- 该劳动合同第**11**条第**1**款约定：“乙方（指黄子瑜）在与甲方（指富日公司）解除本合同后，五年内不得与在解除本合同前与甲方已有往来的客户（公司或个人）有任何形式的业务关系。否则，乙方将接受甲方的索赔。”该劳动合同中没有关于保守商业秘密的约定。
- 本案的争议焦点在于：该劳动合同第**11**条第**1**款是否属于富日公司对其商业秘密采取的保密措施。
- 最高人民法院2011民申字第122号民事裁定书

竞业禁止与保密措施

- 最高人民法院认为：
- 保密措施应当表明权利人保密的主观愿望，并明确作为商业秘密保护的信息的范围，使义务人能够知悉权利人的保密愿望及保密客体，并在**正常情况下足以防止涉密信息泄漏**。
- 本案中，富日公司提供的劳动合同没有明确富日公司作为商业秘密保护的信息的范围，也**没有明确黄子瑜应当承担的保密义务**，而仅限制黄子瑜在一定时间内与富日公司的原有客户进行业务联系，显然不构成反不正当竞争法第十条规定的保密措施。

竞业禁止（1）

- 竞业禁止：单位与知悉技术秘密的人员约定在解除劳动关系后一定时间内，被竞业限制人员不得在生产同一种核心技术产品且有竞争关系的其他单位任职，或者自己从事与原单位有竞争关系的同一种核心技术产品的生产经营。
- 竞业禁止的人员范围：
 - 法定人员：
 - 《公司法》：董事、监事、高级管理人员
 - 《劳动合同法》：高级管理人员、高级技术人员
 - 其他人员：必须签订竞业禁止协议

如果掌握商业秘密，但是没有签订竞业禁止协议，那么也有保护商业秘密的义务

如果不掌握商业秘密，是否有竞业禁止的义务？
那么就不属于竞业竞争的范围

竞业禁止（2）

- 竞业禁止的矛盾
 - 不进行竞业禁止的限制会损害用工单位的利益；
 - 竞业禁止严重限制了劳动者的择业权。
- 法律上的平衡：
 - 合同解除后竞业禁止的期限（一般为2年）；
 - 履行竞业禁止义务期间用工单位应当补偿劳动者的损失。

竞业禁止（3）

- 期限

- **2013年《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》：最长两年。**

- 补偿

- **2013年《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》：终止前十二个月平均工资的30%按月支付（最低标准）。**

保密协议终止后，仍然有保护商业秘密的义务；签订合同后可以有更细化的保密细则，有罚则

保密协议的效力

- 根据《劳动合同法》第二十三条的规定，用人单位可以与劳动者合同约定保守商业秘密的条款。
- 即便劳动者解除劳动合同之后，依然承担保守商业秘密的义务（无限期）。
- 根据《上海市劳动合同条例》，如果商业秘密因进入公共领域失效，保密协议同时失效。
- 用人单位可以就劳动者要求解除劳动合同的提前通知期在保密协议中作出约定，但提前通知期不得超过六个月。（法律规定是一般一个月）

有利于保护商业秘密，公司知道要离职就会提前不将涉及到重要秘密的任务交给劳动者；如果提前时间过长，对于劳动者权益不利

保密协议与经济补偿

- 除另有约定的，签订保密协议的劳动者可以要求用工单位给予经济补偿。
- 问题：劳动者**A**与用工单位**B**签订了保密协议，但没有约定经济补偿。劳动合同解除后，**A**能否主张该保密协议无效？
- 答案：
 - 该保密协议依然有效；
 - **A**可以请求**B**对之进行经济补偿。

侵犯商业秘密行为的构成要件（1）

- 主体要件

- 目前大致认为侵犯商业秘密的行为主体大致有以下四类：

- 1.单位内部工作人员（包括前员工）

- 2.合同保密义务人

- 3.侵权第三人（竞争者）

- 4.教唆、引诱、帮助侵权人

侵犯商业秘密行为的构成要件（2）

- 主观要件：
 - 故意：明知是商业秘密而对于进行侵犯
 - 过失：负有保密义务的主体过于自信或者疏忽大意导致商业秘密被侵犯
 - 不是故意也没有保密义务，则不负责任
- 行为要件：
 - 客观上实施了法律规定的侵犯商业秘密的行为

《反不正当竞争法》第9条

- 经营者（**包括其他主体**）不得采用下列手段侵犯商业秘密：
 1. 以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；**非法获取**
 2. 披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；**非法使用**
合法获取，非法使用
 3. 违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。
 4. **教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密**
修法新增 **帮助侵权**

不属于侵犯商业秘密的行为

- 自行开发
- 反向工程
 - 实践中经常出现侵权人提出证据证明自己是通过逆向工程获得该秘密；
 - 如果原告能够证明被告已经以不正当手段知悉了该秘密的，被告不得通过主张逆向工程来为自己辩解。
- 股东依法行使知情权而获取公司商业秘密的；
- 商业秘密权利人或持有人的员工、前员工或合作方基于环境保护、公共卫生、公共安全、揭露违法犯罪行为等公共利益或国家利益需要，而必须披露商业秘密的。

侵犯商业秘密的举证原则

- 在很多情况下受害人很难证明侵权人实施了侵害商业秘密的行为；
- 举证责任转换

原告的举证责任（第24条）

- 涉案商业秘密属于本法规定的商业秘密
- 权利人能证明涉嫌侵权人所使用的信息与自己主张的商业秘密实质上相同，
- 同时能证明涉嫌侵权人有获取其商业秘密的条件，
- 而涉嫌侵权人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据的。

被告的举证责任

- 自己是涉案商业秘密的权利人（自行开发或者逆向工程）；
- 两个商业秘密非同一；
- 未实施涉案行为。

“优选锯”侵害技术秘密纠纷案

- 优铠公司是一家制造、销售优选锯产品的公司，该公司主张其享有“边测量边锯切”的技术秘密。**2011年12月12日**，曹某、李某、周某等人从优铠公司离职，作为股东出资成立路启公司，其中曹某持股**50%**，李某、周某各持股**25%**。
- 原告认为，被告利用优铠公司的技术秘密制造、销售优选锯产品，侵犯了其商业秘密。
- **（2019）最高法知民终7号**

“优选锯”侵害技术秘密纠纷案

- 法院的认定：
- 技术秘密内容的确定往往涉及繁重的事实认定和复杂的法律判断。
- 路启公司在本案一、二审始终未提交证据证明其制造的优选锯使用的锯切工艺不同于涉案技术秘密的锯切工艺。而本案现有证据足以证明V200优选锯的技术信息与优铠公司“边测量边锯切的设计”的技术信息构成实质相同。

"生意参谋"数据产品案

- 缪某某诉杭州市余杭区市场监督管理局案 浙江高院（2024）浙行终862号
- “生意参谋”数据产品介绍：淘宝公司在收集网络用户浏览、搜索、收藏、加购、交易等行为痕迹所产生的巨量原始数据基础上，以特定的算法通过深度分析过滤、提炼整合并经匿名脱敏处理后形成的以趋势图、排行榜、占比图等图形呈现的指数型、统计型、预测型衍生数据。
- 被诉侵权行为：缪某某将其在某天猫店铺任职而掌握的“生意参谋”子账号提供给案外人杨某某登录使用，供其登录浏览“生意参谋”内商业信息。杨某某要求缪某某查询“宠物行业电动猫砂盆和宠物毛发打理新品两个品类近两年的行业销售额”，缪某某为其提供相关数据截图。

"生意参谋"数据产品案

- 行政处罚情况：余杭区市场监督管理局认定缪某某构成侵害商业秘密的行为，遂作出行政处罚决定，责令缪某某停止侵害商业秘密行为，处罚款5万元 余杭区人民政府维持上述处罚决定。缪某某不服上述决定，起行政诉讼，要求撤销上述行政处罚决定及行政复议决定。



“生意参谋”数据产品案

- 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（下称“京东公司”）系中国知名电商平台“京东商城”运营主体。京东公司依托自身大数据及技术优势推出了与电商营销解决方案相关的数据产品“京准通”，通过大数据分析与特色算法模型，提炼整合出预测型、统计型、特色分类型数据内容，以可视化方式呈现，帮助商家精准定位营销投放人群。广州鱼数科技有限公司等通过伪装成京东商家，以注册成为“京准通”平台用户方式擅自获取“京准通-DMP”提供的数据内容作为自身运营“京店宝”平台数据内容向其用户付费提供事宜，京东公司以不正当竞争为由，将前述三主体诉至北京市西城区人民法院。

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>